

1500903-41.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas."

(TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a):

Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500903-41.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166834/2022 - GOE-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS ANTONIO DONIZETI ROSSI

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 13 dias do mês de setembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e a Defensora Pública, Dra. Daniela Batalha Trettel. Apresentados o acusado LUIS ANTONIO DONIZETI ROSSI, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Rogerio Jose da Silva e Márcio Luis Teixeira de Camargo Barhun.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas (Rogerio e Márcio) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, LUIS ANTONIO DONIZETI ROSSI está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de junho de 2022, por volta de 09h50min, na Rua Paschoal Barsottini, n.º255, Jardim Oriente, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, LUIS ANTONIODONIZETI ROSSI, qualificado e indiciado às fls. 04, 23/26 e 28, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 09 (nove) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, maconha, com peso líquido de 13,9g (treze gramas e nove decigramas) e 09 (nove) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 2g (duas gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, LUIS - que possui envolvimento anterior com o tráfico (Foi preso em flagrante pela mesma prática, e no mesmo bairro, no dia 22 de maio de 2022, estando em liberdade provisória desde o dia 23 de maio de 2022) - se posicionava em via pública conhecida como “ponto de venda de drogas” para comercialização de maconha e cocaína. Ocorre que a intensa prática de tráfico de drogas no local foi informada à Delegacia Especializada, mobilizando agentes “descaracterizados” para averiguação. Em diligência velada, LUIS foi observado em atividade típica de mercancia ilícita: atendeu a um motociclista na via pública, entregou-lhe objeto que escondia sob suas vestes e recebeu objeto em troca. Ao reiterar a movimentação característica do tráfico, foi abordado por investigadores policiais. Em busca pessoal, foram localizadas em sua posse 09(nove) eppendorfs de cocaína e 09 (nove) porções de maconha, além de R\$10,00(dez reais) em espécie (foto fls. 14).Embora tenha informalmente confirmado a traficância, na delegacia o denunciado ficou silente (fls. 04).O exame pericial constatou a presença de cocaína e tetrahidrocannabinol nas substâncias apreendidas (auto fls. 13 e laudos periciais fls. 16/20 e55/57).Considerando as circunstâncias da prisão, notadamente as informações sobre tráfico no local, a visualização de atos característicos do tráfico, a localização de quantidade de droga incompatível coma mera destinação pessoal, bem como dinheiro em espécie, é certo que o denunciado trazia consigo os entorpecentes apreendidos.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Márcio Luiz Teixeira de Camargo Barhun - Policial Civil - narrou que o local é ponto de tráfico. já houve muitas prisões no mesmo local. Estava fazendo serviço velado e viu o réu fazendo uma ou duas vendas. Percebeu que ele estava com as drogas junto ao corpo. Acionou a equipe do GOE e ficou ao vivo no telefone com eles passando as características do réu, para que não fosse abordada pessoa equivocada. Drogas foram encontradas em poder dele e ele disse que vendia os entorpecentes naquele local. Não participa da abordagem para que isso não atrapalhe futuras campanhas. Mas passa as informações aos policiais, inclusive o local exato onde está guardada a droga. No caso, estava junto ao réu. Ele disse que vendia a maconha a cinco reais e dez reais a cocaína. Ele tinha dez reais e disse também ter começado a venda naquele momento. Não conhecia o réu.

Rogério José da Silva - Policial Civil - narrou no mesmo sentido. Foi o policial acionado a fazer a abordagem do réu. O policial Barhun viu o réu negociando drogas. Recebeu de seu colega informações sobre o traficante, inclusive vestes. Abordou o réu e o identificou. Encontrou nove porções de cocaína e nove de maconha e dez reais. Ele confirmou a venda. Disse que vendia a cocaína a dez reais e a maconha a cinco reais. Encaminhou o réu até a Delegacia de Polícia. O réu tinha as características passadas pelo policial Barhun, que ficou ainda um tempo ao telefone com um policial da equipe da abordagem passando as informações e indicando a pessoa a ser abordada.

Interrogado, o réu disse que tinha acabado de comprar as drogas para uso próprio.

Negou traficância.

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-

25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10)

DA PENA

Folha de antecedentes e certidões nos autos (fls. 29/31):

LUIS ANTONIO DONIZETI ROSSI é tecnicamente primário - é processado por tráfico de drogas nos autos n.º 1500748-38.2022.8.26.0599, onde foi beneficiado com a liberdade provisória em 23 de maio de 2022.

Desde já, cumpre destacar o não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, eis que o crime do artigo 33 da Lei de Drogas tem pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão - requisito objetivo do art.28-A do Código de Processo Penal não cumprido - e trata-se de indivíduo que reitera a mesma espécie delitiva - requisito subjetivo não satisfeito.

Pelos mesmos motivos, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Vale reforçar que, em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

DO PEDIDO FINAL

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Elias Cesar Alves foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 89-90), no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 01h15, na rua Governador Pedro de Toledo, número 2201, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Elias subtraiu, mediante o horário de período noturno, para si ou para outrem, mediante escalada, fios e cabos elétricos avaliados em R\$300,00 (trezentos reais) - fls. 6/7 - e pertencentes a Celso Fornazier Camargo Sampaio.

Ainda de acordo com a inicial, o réu aproveitando-se da menor vigilância em razão do período noturno, escalou o imóvel da vítima e se apoderou dos fios e cabos elétricos. Todavia, policiais militares foram informados acerca da conduta delituosa e surpreenderam o réu no telhado do imóvel, carregando o material acima descrito. Durante a abordagem, o réu confessou a prática delitiva.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 5).

Em solo policial, Thiago Fillet da Costa, sobrinho da vítima, contou que: "o imóvel situado na rua Governador Pedro de Toledo é de seu tio. Ele está desocupado, já que está para alugar. Seu tio não se encontra nesta cidade, ficando o declarante responsável pelo imóvel. Hoje, quando tomou conhecimento do furto ocorrido no local foi orientado a comparecer nesta unidade. Não presenciou os fatos. Recebe neste ato os objetos apreendidos na posse do indiciado" (fls. 4).

Camila Maritza Van Der Laan Ferraz, policial militar, narrou que: "recebeu solicitação do COPOM para comparecer na rua Governador Pedro de Toledo, n.º 2201, onde estava ocorrendo um furto de residência. Dirigiu-se até o local e, quando chegava nas imediações do imóvel, visualizou um indivíduo pulando do telhado do imóvel levando consigo um pacote de fios elétricos. Conseguiu abordar o indivíduo. Ao ser questionado sobre o furto, ele assumiu a prática do delito. O indivíduo foi

identificado como sendo Elias Cesar Alves. Diante dos fatos, deu voz de prisão em flagrante à Elias sendo ele apresentado nesta unidade policial. O proprietário do imóvel não foi localizado, sendo apresentado nesta unidade um sobrinho dele, o qual se responsabilizou pelos objetos apreendidos" (fls. 2).

No mesmo sentido a versão apresentada por Thiago Expedito Souza Novais, policial militar (fls. 3).

As fls. 31-33, certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 0003880-10.2020.8.26.0451 - furto privilegiado - trânsito em julgado para a Defesa em 5/3/2020).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 8, fotografias de fls. 11 e laudo de exame do local dos fatos de fls. 112-115 ("[...] foram constatados esfregaços característicos de escalada [...] amassamentos na cerca elétrica logo acima dos esfregaços e supressão de parte da fiação elétrica ali existente [...] - fls. 13)

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, ouvida Camila Maritza Van Der Laan Ferraz, policial militar. Relatou que o local era uma casa para alugar. Foram chamados de madrugada. O réu estava saltando de cima da casa com os fios. Quando viu a polícia, o réu tentou se esquivar da viatura. O local é bem na esquina e, na hora em que tentou fugir, foi abordado. Ele disse que haveria outra pessoa, mas não viram. Ele mesmo desceu do telhado. Estava com fios, jogou. Tinha um papelão, ele tentou esconder os fios. Ele ingressou na residência pelo lado, tem um portão baixo no vizinho. Eles sobem por essa lateral. Tinha até marcas dos pés no muro. Não se recorda do que o réu disse no momento. Ele disse que estava com mais alguém, mas não viram ninguém. Não conhecia o réu.

b) Por fim, o réu Elias Cesar Alves foi interrogado.

- DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA

Tendo em vista que o objeto subtraído foi restituído à vítima, o caso é de absolvição por atipicidade material da conduta, em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse contexto, de início, saliente-se que insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, como afirma, a propósito, Paulo Queiroz:

"O princípio da insignificância constitui, portanto, um instrumento por cujo meio o juiz, em razão da manifesta desproporção entre crime e castigo, reconhece o caráter não criminoso de um fato que, embora formalmente típico, não constitui uma lesão digna de proteção penal, por não traduzir uma violação realmente importante ao bem jurídico tutelado" (Direito penal: parte geral, v. 1. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 91).

Dinamizando a incidência da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, fixou o entendimento sobre a necessidade da verificação de quatro pressupostos para sua aplicação: a) a pequena ofensividade da conduta do agente; b) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) nenhuma periculosidade social da ação; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada:

"E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPLICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R\$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPLICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c)

o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social." (HC 84412, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. em 19/10/2004).

Este julgado tornou-se o verdadeiro leading case da matéria e vem sendo reiterado por inúmeras decisões, tanto do próprio Supremo Tribunal Federal, quanto deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes: a) no STF: HC 97129/RS, Min. Rel. Eros Grau; HC 97189/RS, Min. Rel. Ellen Gracie; STF, HC 96496/MT, Min. Rel. Eros Grau; HC 105974, Min. Rel. Ayres Britto; HC 93393, Min. Rel. César Peluso; HC 93453, Min. Rel. Joaquim Barbosa; b) no STJ, RHC 23.376/MG, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho; HC 198996/SC, Min. Rel. OG Fernandes; HC 34626/MG, Min. Rel. Félix Fischer; STJ, HC 18314/RJ; HC 139015/SP, Min. Rel. OG Fernandes; HC 122435/MG, Min. Rel. Celso Limongi.

Ora, a aplicação do princípio da insignificância é uma questão de política criminal, afastando a intervenção penal para delitos que, do ponto de vista jurídico-penal, são considerados menos reprováveis. E, ao fazê-lo, permite-se que o poder punitivo seja exercido de forma mais enérgica em relação aos delitos que, efetivamente, atentam contra a paz social.

Saliente-se, ainda, que o reconhecimento da insignificância não irá causar qualquer desamparo à vítima. Pelo contrário, o que se postula é que seja reconhecida a insignificância do ponto de vista jurídico-penal. Ou seja, o que se requer é o afastamento das consequências jurídico-penais. Com isso, a vítima, caso entenda que tenha sofrido algum tipo de prejuízo, ainda poderá pleitear a devida reparação na esfera civil, eis que a sentença que reconhece a atipicidade da conduta não produz coisa julgada na esfera extrapenal (CPP, art. 67, III). Percebe-se, dessa forma, que somente se justificaria manter a persecução penal para assegurar à vítima um título executivo judicial, eis que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar (CP, art. 91 c. c/ CPC, art. 515, VI). Todavia, é necessário separar as esferas penal e civil e, assim, retiradas as consequências jurídico-penais da conduta, não se justifica a manutenção do processo penal, seja por causa dos inúmeros gravames que serão causados ao imputado, seja pelo fato que os interesses da vítima - meramente econômicos - ainda estarão amparados pelo ordenamento.

Se é assim, impõe-se a absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Caso a insignificância não seja aplicada ao presente caso, imperiosa a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações deles são

tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão, ainda que seja apenas a informal.

c) Do repouso noturno

Conforme decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a majorante do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado.

A nova orientação jurisprudencial se baseia na topografia do artigo de furto - que traz o aumento de pena (§ 1º) antes de descrever as condutas consideradas qualificadas (§ 2º) - e, portanto, passou a considerar que a aplicação somente pode ocorrer nos casos de furto simples.

Ademais, o Ministro Relator argumentou que, caso o entendimento fosse diverso, a pena de furto qualificado e majorado pelo repouso noturno seria, em tese, superior à do delito de roubo, o que violaria o princípio da proporcionalidade.

Embora recente, a tese já tem sido aplicada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

"A tese defendida pela defesa está em sintonia com a nova jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua formação qualificada (§ 4º) - (REsp n. 1.888.756/SP, n. 1.891.007/RJ, e n. 1.890.981/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, sessão do dia 25/5/2022 - grifo nosso)". (REsp n. 1.965.441, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 01/06/2022.)

Nesse sentido, também já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"FURTO QUALIFICADO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.

Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão da res furtiva em poder do apelante. Crime praticado mediante rompimento de obstáculo.

Repouso noturno em furto qualificado. Não incidência. Jurisprudência consolidada.

Condenação mantida.

(TJ-SP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 1500169-55.2019.8.26.0580, Rel. Gilberto Ferreira da Cruz, julgado em 6/7/2020, grifos nossos)".

Assim também se manifesta a doutrina:

"É furto agravado ou qualificado o praticado durante o repouso noturno, aumentando-se a pena de um terço (art. 155, § 1º).

[...].

A agravação da pena em um terço é procedida sobre a reprimenda do furto simples e,

por isso, não se refere às hipóteses de furto qualificado" (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal: parte especial, arts. 121 a 234 do CP. 26. ed. rev. e atual. até 11 de março de 2009. São Paulo: Atlas, 2009, p. 196, grifos nossos, p. 193).

Sendo assim, a causa de aumento do repouso noturno não deve ser aplicada à presente hipótese.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em caso de soltura, requeiro que se recomende ao CDP tentativa de contato com a família, para que sejam avisados da sua soltura.

Em seguida pela MM.Juiza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

LUIS ANTONIO DONIZETI ROSSI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de junho de 2022, por volta de 09h50, na Rua Paschoal Barsottini, n.º 255, Jardim Oriente, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 09 (nove) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L., maconha, com peso líquido de 13,9g (treze gramas e nove decigramas) e 09 (nove) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 2g (duas gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, LUIS – que possui envolvimento anterior com o tráfico - se posicionava em via pública conhecida como “ponto de venda de drogas” para comercialização de maconha e cocaína.

Ocorre que a intensa prática de tráfico de drogas no local foi informada à Delegacia Especializada, mobilizando agentes “descaracterizados” para averiguação. Em diligência velada, LUIS foi observado em atividade típica de mercancia ilícita: atendeu a um motociclista na via pública, entregou-lhe objeto que escondia sob suas vestes e recebeu objeto em troca. Ao reiterar a movimentação característica do tráfico, foi abordado por investigadores policiais.

Em busca pessoal, foram localizadas em sua posse 09 (nove) eppendorfs de cocaína e 09 (nove) porções de maconha, além de R\$10,00 (dez reais) em espécie (foto fls. 14).

Embora tenha informalmente confirmado a traficância, na Delegacia o réu ficou silente (fls. 04).

O exame pericial constatou a presença de cocaína e Tetrahydrocannabinol nas substâncias apreendidas (auto fls. 13 e laudos periciais fls. 16/20 e 55/57).

A denúncia foi oferecida (fls. 63), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 68/69).

Notificado (fls. 74), o réu apresentou defesa prévia, na qual aduziu a inexistência de questões preliminares e informou que irá se manifestar sobre o mérito ao final da instrução processual, além de requerer a revogação da prisão preventiva com fixação das medidas cautelares diversas da prisão (fls. 78/81).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência (fls. 90/92). O réu foi citado (fls. 109).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado. Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 13, na fotografia de fls. 14, no laudo de constatação de fls. 16/20, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 55/57, segundo o qual foi detectada a presença de cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 04).

Em Juízo, o réu afirmou que foi buscar a droga para seu próprio uso. Tinha comprado a droga e queria sair do local. Comprou maconha e cocaína e sobrou R\$ 10,00 do seu dinheiro. Pagou R\$ 75,00 pela droga. Não conseguiu ver a quantidade de droga que comprou, porque estava alucinado. Não se recorda onde estava a pessoa que lhe vendeu a droga. Não sabe dizer como estava a pessoa que lhe entregou a droga, se estava a pé, de moto, de carro, de bicicleta. Estava entre a placa e o ponto de ônibus, quando foi abordado. Faz uso de crack, cocaína e maconha.

A autoria foi comprovada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

O policial civil Márcio Luiz Teixeira de Camargo Barhun relatou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e, por isso, efetuaram inúmeras prisões no mesmo local. Permaneceu sozinho, em monitoramento velado e fica observando a pessoa que está na prática do tráfico de drogas. Quando consegue identificar o traficante, faz contato com outros policiais, que efetuam a abordagem. Fica no visual, para que os outros policiais efetuem a prisão da pessoa correta. No dia dos fatos, visualizou o réu efetuando a venda para pessoas com veículo. Ele fez duas vendas, uma para um motociclista e outra para um veículo. Viu que o réu guardava a droga num determinado ponto e avisou a equipe. Acompanhou a abordagem do réu, a fim de que o traficante seja abordado. No caso dos autos, informou que a droga estava no corpo do réu, onde ela foi encontrada. Na Delegacia, teve contato com o réu, que confirmou que vendia a R\$ 5,00 a maconha e R\$ 10,00 a cocaína. O réu tinha R\$ 10,00 consigo, porque tinha começado a venda naquele momento. Não conhecia o réu.

O policial civil Rogério José da Silva narrou que saíram para combater o tráfico de drogas em local já conhecido pela prática desse delito. Bahrum ficou de forma velada, bem ao lado de uma praça e ele e o restante da equipe ficaram nas proximidades, esperando o momento da abordagem. Bahrum conseguiu ver um indivíduo com determinadas características entregar algo para um motociclista e recebendo algo dele. Foi ao local e abordou o réu. Com ele, havia 09 porções de cocaína, 09 porções de maconha e R\$ 10,00. O réu confirmou que estava vendendo as drogas. O réu tinha as mesmas características que foram descritas pelo policial Bahrum, inclusive ele ficou observando a abordagem e confirmou que era o réu. Não conhecia o réu.

Foram ao local, mas não tinha denúncia sobre o réu.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Na Delegacia, o réu permaneceu silente. Judicialmente, o réu alegou que tinha adquirido a droga para seu consumo, pouco antes de ser abordado.

Segundo a prova oral, realizando investigação de tráfico de drogas no bairro Jardim Oriente, as equipes policiais se dividiram, de modo que o policial Bahrun permaneceu sozinho, em viatura descaracterizada, na Rua Paschoal Barsotini, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, enquanto o policial Rogério e o restante da equipe, em viatura caracterizada, permaneceram nas proximidades. Bahrun visualizou o réu fazendo contato com um motociclista, retirando alguma coisa de suas vestes e entregando-a ao motociclista, que lhe entregou dinheiro em troca. Após visualizar a mesma conduta por outra vez, com o condutor de um veículo, o policial Bahrun acionou Rogério, que foi ao local e, com as características do réu, o abordou. Em revista pessoal, com o réu, Rogério apreendeu 09 porções de cocaína, 09 porções de maconha e R\$ 10,00 em espécie. Questionado sobre a droga, informalmente, o réu confessou que estava realizando a venda dos entorpecentes. Considerando que o réu confirmou que a droga apreendida estava em sua posse, inexistente contradição quanto a esse fato.

Ainda que assim não fosse, devemos dar crédito ao depoimento uníssono e seguro dos policiais civis que, como funcionários públicos, não estão impedidos de depor. Por

outro lado, a palavra dos agentes públicos tem validade como prova, em especial quando, como nos autos, encontra amparo no restante da prova.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Comprovado o envolvimento do réu com a droga apreendida, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprova a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu alegou que o entorpecente era para seu próprio consumo. Outros elementos de prova confirmam que a droga era para o consumo de terceiras pessoas. Vejamos.

Inicialmente, os policiais estavam em local conhecido como ponto de venda de drogas.

O policial Bahrin visualizou o réu fazendo contato com motociclista e o condutor de um veículo, entregando algo e deles recebendo dinheiro, em atividade típica de

tráfico de drogas. Aliás, o réu permaneceu no local por algum tempo, fato que não é comum com os usuários de drogas.

Além disso, a quantidade e diversidade de drogas (09 porções de maconha e 09 porções de cocaína) são superiores àquelas que normalmente são localizadas com usuários de drogas.

Assim, o local da abordagem, a situação fática presenciada por Bahrun, a quantidade e diversidade da droga e sua forma de embalagem e o dinheiro apreendido; tudo revela que a droga tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal -Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câmb. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor, não sendo cabível a desclassificação.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa.

O artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 pode ser aplicado ao caso concreto.

O réu é primário, embora responda por processo que o acusa da prática do mesmo delito, e a quantidade de entorpecente apreendido não era considerável (13,9g de maconha e 2g de cocaína), além disso, não há notícias de que ele se dedicasse a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, tem direito à redução: reclusão de 01 ano e 08 meses e 166 dias-multa.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

Diante da jurisprudência que vem se fixando nos Tribunais Superiores, o regime inicial de pena cominada ao delito de tráfico de entorpecente privilegiado deve ser

o aberto.

Pena final: reclusão de 01 ano e 08 meses, e regime inicial aberto, e 166 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR LUIS ANTONIO DONIZETI ROSSI, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 01 ano e 08 meses, e regime inicial aberto, e 166 dias-multa, diária mínima.

Tendo em vista as novas orientações jurisprudenciais, como o réu é primário e o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo.

Em razão da pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado. Nos termos do pedido da Defesa, recomende-se ao CDP a realização de contato com a família do réu, a fim de que sejam avisados sobre a sua soltura, em razão da sua situação de risco social.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu (comprovante de depósito a fls. 53) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

PELO RÉU E SUA DEFENSORA FOI DITO QUE NÃO TÊM INTERESSE EM RECORRER DA R.SENTENÇA.

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):